

1500399-98.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500399-98.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-98.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAYSSON ODESIO DAS NEVES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. LAYSSON ODESIO DAS NEVES FERREIRA, qualificado a fls. 19, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343, de 23.08.2006, porque no dia 17 de julho de 2021, por volta das 10h30min, na Rua 46-B nº 179, Bairro João Vacaro, em frente à Unidade de Saúde da

Família Cabo Agnaldo Soares Barbosa, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria em depósito, para finalidade de entrega ao consumo de terceiros, duas porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,560 g, além de onze porções de crack, com peso líquido de 4,770 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que “policiais militares receberam a informação de que um indivíduo estava no local dos fatos realizando a venda de drogas e que escondia os entorpecentes ao pé de uma árvore.

Diante da notícia recebida, os agentes públicos citados foram ao local indicado e ali avistaram o denunciado, o qual foi até uma árvore, abaixou-se e pegou algo. Os policiais, então, abordaram o denunciado, instante em que ele jogou ao chão o que trazia em suas mãos, constatando os agentes se tratar de um eppendorff contendo cocaína.

Na árvore em que o denunciado foi visto inicialmente, os policiais encontraram um saco plástico contendo outros dois eppendorffs com cocaína e onze pedras de crack envoltas em papel branco.

Em poder do denunciado, os agentes públicos ainda encontraram a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em notas diversas.”.

Denúncia de fls. 124/126 recebida em 16 de agosto de 2021 (fls. 127/128). Devidamente citado (fls. 136), o Acusado apresentou defesa preliminar (fls. 143/144), rejeitada por não configurar o caso de absolvição sumária (fls. 150/152). Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 199/204).

Em alegações finais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 197/198).

A douta Defesa, por sua vez, ressaltou que o Réu deveria ser absolvido por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, não sendo o caso, fixação da pena no piso (fls. 205/211).

Eis o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/05), boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 12/14), no relatório de investigação de fls. 118/119, comprovante de depósito de fls. 138, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 184/186) e pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu que em Juízo negou o teor da denúncia, sustentando, a fls. 202/204, que no dia dos fatos estava com sua prima Leandra descendo para casa de Ana Beatriz quando passou entre a 25 e a 46-B, oportunidade em que os policiais abordaram e realizaram sua abordagem, mas não em sua prima, porque mulher, colocando ambos sentados e passaram a procurar na pracinha, voltando em seguida com um saquinho transparente contendo a droga que, contudo, não tinha conhecimento, somente sabendo que se tratava de droga no interior da viatura, ao questionar os policiais, reafirmando que o entorpecente não era seu. Ademais, afirma que era usuário de cocaína e atualmente trabalha na lavoura.

Sua versão não se sustenta sendo que, verdadeira, teria feita robusta produção probatória, mormente fazendo ouvir suas primas, mormente Leandra, que teria tudo presenciado, ônus que lhe competia, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal.

De fato, o policial militar Bruno disse, em fls. 199/201, que foram informados que um indivíduo estaria traficando drogas naquele conhecido ponto de vendas, guardando em frente à praça do Posto do João Vacaro, no pé de uma árvore, para lá se dirigindo, encontrando o Réu agachado mexendo no pé da árvore e se deslocando ao ponto de venda, distante cerca de vinte metros, com o que realizaram sua abordagem, instante em que o Acusado jogou um eppendorff aberto com substância aparentando ser cocaína e, em busca pessoal, encontraram dinheiro em notas diversas, solicitando apoio e retornando ao ponto em que ele mexia, ali localizando um plástico contendo dois eppendorfs idênticos ao que ele se desfez e também, dentro do saco, pedras de crack. Ademais, declarou que o Réu era conhecido dos meios policiais, no local várias prisões já foram realizadas e ele não aparentava estar sob efeito de droga.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policial, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não pode ser descartado, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência válida ao seu depoimento, nem mesmo o contraditando.

A condição funcional não o torna suspeito, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

A conduta do Acusado indica, pois, que no dia, horário e local apontados na denúncia, tinha em depósito, em uma praça em frente à Unidade de Saúde da Família, substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente diversidade e quantidade de droga apreendida, em porções individuais prontas para comercialização, bem como a forma como estava o narcótico escondido em uma árvore, sendo avistado no momento em que ali mexia, além do fato de que ele, ao avistar os policiais militares, se desfez de uma porção, assim como por ser conhecido dos meios pela prática do narcotráfico, ali um notório ponto de venda de drogas.

Tais condutas apontam que o Réu iria utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Importante destacar que o simples fato de ser usuário de drogas – sequer comprovado – não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, tais condutas caminham juntas, o que impede a desclassificação pretendida.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel.

Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

De outro modo, é forçoso se reconhecer que o Acusado traficava em frente à Unidade Básica de Saúde Cabo Agnaldo Soares Barbosa, conforme relatório de fls. 118/119. Assim, perfeitamente caracterizada a causa de aumento de pena tipificada no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicados na denúncia o Acusado foi surpreendido quando tinha em depósito, para fins de comercialização, a substância entorpecente descrita na inicial.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo à dosimetria da pena.

Nesta fase inicial, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei de Drogas, é o caso de majorar a pena-base, tendo em vista que o Réu é portador de antecedente (cf. fls. 35), demonstrando que apesar de jovem persiste na prática de ilícitos, de forma que majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo inicialmente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, à míngua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase, tem-se que o Acusado era menor de 21 anos à época da consumação do crime, retornando sua pena ao mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão. Ainda nesta fase, rejeito a pretensão de majoração da pena com base no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não há qualquer indicação de que tenha o Réu se aproveitado da pandemia para praticar o crime de tráfico, não se verificando relação direta deste período de exceção com a prática do ilícito, não se podendo admitir interpretação extensiva a ponto de se exacerbar a condenação somente pelo momento em que praticado o delito, sob pena de se tornar padrão para todo e qualquer crime praticado durante o tempo em que grassar a peste. Nesse diapasão: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito. 3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados" (STJ, HC 654.255/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.05.2021 - grifei).

À derradeira, em vista da incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, majoro sua pena em 1/6, à míngua de critérios que indicassem possibilidade de se aumentar a pena acima da fração mínima, e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu piso legal.

Não havendo qualquer demonstração nos autos de que se dedique à atividade criminosa organizada, malgrado praticasse o narcotráfico, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. No caso dos autos, dadas as circunstâncias particulares, não havendo qualquer demonstração clara de tratar-se de pessoa envolvida com a criminalidade organizada, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no seu piso, que torno definitiva ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Neste ponto, é de se reconhecer que o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que o tráfico privilegiado não tem natureza de crime equipado ao hediondo, verbis: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.
2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
4. Ordem concedida" (HC118.533/MS, Relª Minª Carmen Lúcia, j. 23.06.2016).

Desta forma, tomando por base a ausência de hediondez do tráfico privilegiado, assim como sua primariedade e menoridade relativa, sua pena deverá ser cumprida desde o início em regime aberto, o que é aqui consignado por determinação legal (artigo 59, inciso III, do Código Penal) e em face de eventual e futura revogação das penas restritivas de direitos sobre as quais se falará a seguir. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 e no seu parágrafo 2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade assistencial (artigo 43, inciso I, do Código Penal) e prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), pelo prazo da condenação, que devem ter seu cumprimento fixado pelo Juízo das Execuções Criminais.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizada quantia em dinheiro vinculada ao crime, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu (cf. fls. 138), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu LAYSSON ODESIO DAS NEVES FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, em regime aberto, sendo que a pena de reclusão é substituída, por igual prazo, por pagamento de 1 (um) salário mínimo à entidade assistencial desta Comarca e à prestação de serviço

à comunidade ou à entidade pública, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais. No mais, decreto o perdimento do valor apreendido com ele, este depositado em fls. 138 em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lancem seus nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhe-se o dinheiro apreendido em fls. 138 em favor da União.

Tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se mostra necessária a decretação de sua prisão cautelar, podendo aguardar o julgamento do recurso em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA